

1501017-12.2022.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 12,28 gramas de maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 102), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 108/109.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 06 de maio de 2.022 (fls. 110/112).

Em audiência, foram ouvidas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501017-12.2022.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501017-12.2022.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2013221/2022 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 16529354 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 4, 6361/21/050 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2013221 - 2ª ENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

LUCAS ROBERTO FALCAO TIMOTEO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

LUCAS ROBERTO FALCÃO TIMOTEO foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 22 de setembro de 2.021, por volta das 10h20, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária II de Bauru, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, 12,28 gramas de maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 102), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 108/109.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 06 de maio de 2.022 (fls. 110/112).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 141 -

audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 151/153).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 157/163, alegando que: 1)- segundo documento constante dos autos, vários presos foram conduzidos ao setor de inclusão na mesma data, e a afirmação dos agentes, de que as pessoas detidas ficam sozinhas nas celas é um erro, pois eles quiseram dizer apenas que tais presos não ficam juntos dos demais detentos que já estavam na unidade; 2)- o setor de inclusão tem apenas sete celas, sendo impossível que todos os presos flagrados com objetos ilícitos fiquem separados e sozinhos; 3)- na mesma data da audiência destes autos (19/07/2022), outra foi realizada e, em ambos os processos, os acusados relataram ter sido encaminhados ao setor de inclusão com dezenas de outros presos, o que é também comprovado pelos documentos acostados aos autos; 4)- as imagens do body scanner não vieram aos autos; 5)- é comum que presos flagrados quando retornam ao presídio confirmem a ingestão de drogas, o que confere verossimilhança à versão dos dois réus; 6)- a lista trazida aos autos não se refere a todos os presos que retornaram da saída temporária, mas aos que, em 22/09, expeliram drogas; 7)- a maconha havia sido engolida por outro preso e, quando ele vomitou, havia grande quantidade de casos de ingestão de invólucros de droga por outros detentos, de modo que os agentes separaram parte daquele material e disseram que "ele havia engolido ou que houve um erro na separação"; 8)- não há prova física de que o réu engoliu droga e nem dele no aparelho, de modo a ser possível afirmar que era ele no scanner e que realmente ingeriu entorpecente; 9)- os depoimentos dos agentes penitenciários não são suficientes para a condenação; 10)- deve ser afastada a majorante mencionada na denúncia, pois não aplicável aos presos e por inexistir prova de que o agentes se valeu da aglomeração de pessoas ou da exposição dos frequentadores para disseminar droga. Pediu a absolvição e, em caso de condenação, requereu o afastamento da majorante e a fixação do regime inicial semiaberto.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 08 e pelo laudo pericial de fls. 10/14 (onze porções de maconha com peso de 12,28 gramas).

A autoria deriva da prova oral e deve ser atribuída ao acusado.

Em juízo, a testemunha Emerson Jose Alves, agente de segurança penitenciária, afirmou que o réu foi submetido ao aparelho body scanner quando retornava da saída temporária. Constatou imagem suspeita no estômago. Indagado, o acusado, inicialmente, não quis dizer mas, depois, confessou que trazia drogas para a unidade prisional. Ele foi conduzido a uma cela no setor de inclusão e, de livre e espontânea vontade, prometeu expelir o entorpecente. Porém, ele não conseguiu fazê-lo naquela data.

Somente alguns dias depois, o réu expeliu a droga e a entregou. No setor de inclusão, ficam presos em cela reservadas para aqueles flagrados no scanner com algo estranho. Eles ficam separados e sozinhos, somente sendo reintegrados à população prisional após expelir o objeto. Quando o preso expelle o objeto estranho, chama um agente para a constatação. Os presos ficam sozinhos na cela até expelirem o objeto estranho e apenas têm novo contato com os demais posteriormente. Na sindicância interna, é juntada impressão do scanner. Quando há flagrante de algo suspeito, o pessoal do setor de portaria e que opera o aparelho imprime a imagem e a encaminha ao setor de sindicância. Trabalha nesse setor de portaria. O réu entregou, salvo engano, onze invólucros de maconha. No setor de inclusão, há sete celas. Durante o retorno da saída temporária, quando presos são flagrados no body scanner, muitos já conseguem vomitar o item ilícito. Aqueles que não conseguem fazê-lo permanecem separados nas celas do setor de inclusão até entregar os objetos, quando então são realocados nas demais celas. Se dez presos entregaram as drogas no dia 22, não se recorda como foram alocados nas sete celas. Os presos flagrados ficam num corredor do setor de inclusão, algemados, e depois vão entrando nas celas, um de cada vez e acompanhados de um agente, aguardando-se que expilam ou evacuem o "ilícito".

A testemunha Rodrigo Marcos Rodrigues, também agente de segurança penitenciária, relatou que o acusado retornava da saída temporária e foi submetido ao scanner. Constatou-se imagem suspeita. O réu confessou que trazia maconha e foi conduzido

para cela de inclusão. Ele disse que expeliria o objeto espontaneamente. Dois dias depois, o acusado chamou um funcionário informando que iria expelir o entorpecente e entregá-lo. Muitos presos são trancados na cela da inclusão. No referido setor, são seis celas e uma sétima, à parte. Antes da saída temporária, as celas são esvaziadas porque, no retorno, há muitas ocorrências e são necessários espaços para abrigar sentenciados que apresentem imagens suspeitas. Em princípio, é colocado um preso em cada cela. Se há mais casos suspeitos, colocam-se outros nas celas. Em geral, o preso chama o funcionário que está tomando conta e diz que vai expelir e entregar o que tem. É comum que presos peçam água para beber, a fim de expelir. Interrogado em juízo, o réu afirmou que retornava da saída temporária de setembro. Saiu de sua cidade, situada a 400 km de Bauru, vindo de ônibus, alimentando-se bastante, pois a refeição no retorno é pouca na unidade. Chegando na penitenciária, foi escolhido na fila para ser submetido ao scanner. O aparelho indicou uma "mancha". O funcionário lhe indagou o que tinha no estômago. Respondeu que nada trazia e que deveria ser algo de sua alimentação. O funcionário insistiu que ele tinha algo e o levou para a cela da inclusão. Deram-lhe cartucho e laxante, determinaram que os ingerisse e defecasse o que tinha na barriga. Falou que iria defecar e provar que nada tinha. Estava há onze anos preso, sem ver sua família. Até o dia seguinte, defecou no cartucho e mostrou para o funcionário. Ele lhe pediu que apertasse. Assim agiu e foi constatado que não havia nada. Mesmo assim, foi levado para a cela do castigo, onde já havia outros presos. O diretor da unidade foi chamado e informado que ele, réu, tinha droga no estomago. Explicou-lhes que o procedimento correto impunha que fosse levado ao hospital, onde seria constatado se, de fato, tinha droga. O agente disse que não o levaria para lugar nenhum e que ficaria no castigo. Ali permaneceu com vários outros presos. Três dias depois, foi chamado para ser ouvido. Perguntou para a mulher que tomava seu depoimento do que estava sendo acusado. Ela explicou que era suspeito de trazer droga e lhe exibiu onze porções de maconha. Deu seu depoimento, foi levado de volta para o castigo e depois, mandado de bonde para outra unidade. Na cela do castigo, havia ralo e privada. Se tivesse droga, não iria entregá-la na mão do funcionário. Na cadeia, lava roupa para os outros e faz faxina, para conseguir comprar itens de que necessita. Não conhecia os agentes. Os responsáveis por sua detenção não foram os que vieram prestar depoimento. Havia bonde e escolta para levá-lo ao hospital. No entanto, os funcionários não quiseram levá-lo ao hospital. Eles preferiram deixá-lo na cela de inclusão. Os agentes não disseram que lhe deram laxante. Logo após voltar de "saidinha", iria embora. Sua condicional estava montada. Não sabe se foram gravadas imagens quando passou pelo body scanner. Os agentes viram o que defecou. Nos outros processos do mesmo dia, pode-se ver a mesma embalagem em relação aos demais presos detidos.

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

O fato e sua autoria estão bem demonstrados.

Com efeito, segundo os agentes de segurança penitenciária, ao ser o réu submetido ao aparelho body scanner, foi constatada a existência de imagem suspeita. Ele foi encaminhado ao setor de inclusão, onde, dias depois, expeliu onze invólucros de maconha.

Não há razão para não atribuir credibilidade aos depoimentos dos agentes.

No particular, é lícito questionar: por qual razão dois servidores públicos perderiam seu tempo de iniciar um procedimento administrativo e depois vir em juízo para, na presença do magistrado, afirmar fatos inverídicos em detrimento de pessoa que sequer conheciam, correndo o risco de serem responsabilizados administrativa e criminalmente pela falsa acusação ?

Ademais, no presente caso, as afirmações dos agentes se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

Confira-se, à propósito, o seguinte julgado:

"(...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais

narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão." (HC 254.312/Sp, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013, DJE 13/08/2013). (em TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

Prosseguindo, segundo o documento de fls. 23/24, dez presos flagrados em 20/09/2021 pelo aparelho body scanner e/ou detector de metais quando retornavam da saída temporária expeliram os itens ilícitos em 22/09/2021.

Tal circunstância levou a defesa a questionar como poderiam esses dez presos ficarem cada qual em uma cela, sozinhos, já que, no setor de inclusão, havia apenas sete celas.

É evidente que, separando-se dez pessoas, elas não podem caber, se colocadas sozinhas, em sete espaços.

Porém, deve-se ter em vista que, segundo os depoimentos dos agentes, assim que um desses presos dispôs-se a expelir o objeto estranho captado em seu corpo com auxílio da tecnologia, o funcionário responsável pela vigilância do setor de inclusão foi chamado para acompanhar a situação e receber das mãos deles os itens expelidos.

Nesse sentido, veja-se que a relação de fls. 23/24 é bastante específica, nominando-se cada um dos dez presos e indicando exatamente aquilo que foi expelido, inclusive com menção às quantidades, tudo de forma individualizada.

Não é possível, assim, falar em confusão ou erro na atribuição de objeto expelido por um preso a outro, já que, como visto, o corpo funcional do estabelecimento realizou trabalho específico e criterioso, levando em conta a situação de cada um dos dez detidos que expeliram materiais na data de 22/09/2021.

Não bastasse, ao contrário do que disse o réu em seu interrogatório, é fora de dúvida que ele foi um dos flagrados pelo body scanner como portador de algo estranho em seu abdômen.

O próprio Lucas admitiu ter sido submetido ao body scanner.

Ele também disse que, na imagem, apareceu uma mancha, a qual atribuiu ao fato de ter se alimentado bastante no trajeto de retorno para Bauru por 400 km, em razão de ter em vista ser pouca a quantidade de refeição servida na chegada ao estabelecimento prisional.

Evidentemente, tal narrativa não pode ser aceita.

Muitos presos, quando regressam à unidade prisional, partem de destino longínquo e, se todos eles muito se alimentassem durante o trajeto, certamente haveria a mesma constatação pelo aparelho de revista.

Logo, numa saída temporária, existiriam muito mais detentos tidos como suspeitos. Aliás, o réu sequer demonstrou que se alimentou de forma abastada nas horas que antecederam sua submissão ao scanner.

E ele bem poderia ter trazido tal comprovação, bastando que arrolasse como testemunhas os demais presos que viajavam no mesmo ônibus de regresso.

Note-se, mais, que, em relação a Lucas, a informação de fls. 24 descreveu que, após constatação da imagem suspeita, ele admitiu que havia ingerido onze porções de substância esverdeada, tendo ficado isolado na inclusão e expelido os invólucros em 22/09/2021, entregando-os aos servidores.

Tudo, diga-se, conforme relatado pelos agentes de segurança penitenciária que prestaram depoimentos em juízo, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, não se pode olvidar ato falho cometido pelo réu em seu interrogatório judicial: ao mesmo tempo em que ele afirmou que os agentes responsáveis por sua abordagem e detenção não foram os que prestaram depoimentos em juízo, relatou também que estes se omitiram em dizer que lhe deram "cartucho" e laxante.

Destarte, pese embora inexistam foto do réu sendo submetido ao aparelho de revista e imagens impressas daquilo que foi visualizado no body scanner, é possível considerar verdadeiro, de forma estreme de dúvidas, que ele trazia em seu abdômen as porções de maconha apreendidas.

Por outro lado, como, em nenhum momento se alegou que a droga seria destinada ao consumo e considerando, mais, que o réu não iria arriscar sua saúde e sua liberdade (a qual, segundo o próprio, era iminente) se não houvesse perspectiva de vantagem

maior do que a mera saciedade do vício por curto período, a outra conclusão não se pode chegar senão à de que ele pretendia entregar o entorpecente a terceiros. Impõe-se, pois, a condenação na forma proposta na denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu é reincidente (fls. 91 e 93).

Diante disso, eleva-se a pena na proporção de um sexto, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Deve incidir a causa de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei Antidrogas.

Não há que se pensar no afastamento da majorante em questão sob argumento de, no caso, o autor do delito ser um detento e não um terceiro alheio à população carcerária, pois a lei não faz distinção.

Nesse sentido:

"De igual modo, é caso de manter o aumento decorrente do fato de ter sido praticado o delito nas dependências de estabelecimento prisional, incidindo, na espécie, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Ressalte-se que referida majorante não deixa de incidir quando o agente é detento do presídio, porquanto a lei não traz qualquer particularização a respeito da característica do autor do crime. O colendo Superior Tribunal de Justiça já havia assentado entendimento de que a causa de aumento prevista no inciso IV do artigo 18 da antiga Lei n. 6.368/76 era aplicável ao presidiário que comete o crime de tráfico de entorpecentes nas dependências do estabelecimento penal: 'Para incidência da causa de aumento prevista no artigo 18, inciso IV, da Lei n. 6.368/76, in casu, delito cometido dentro do estabelecimento penal, pouco importa que o crime tenha sido praticado por agente que esteja em liberdade ou por preso. (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ)'. (REsp 662779/MG; Recurso Especial 2004/0078379-7, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma)." (em TJSP, Apelação n. 0000339-05.2010.8.26.0326, Rel. Borges Pereira, j. 04/12/2012).

Do mesmo modo, não resta afastada a causa de aumento em razão de inexistir prova de que o réu se aproveitou da aglomeração de pessoas para a prática criminosa.

Na verdade, o tratamento mais rigoroso para aquele que é surpreendido cometendo tráfico nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional deve-se ao fato de se tratar de local que, mais do que outros, precisa ser mantido a salvo do mal da disseminação das drogas, pois está sob autoridade estatal e serve de espaço para reeducação e ressocialização dos presos, finalidade cara à sociedade brasileira.

Não interessa, pois, verificar se o agente valeu-se ou não de aglomeração de pessoas para perpetrar o tráfico.

Elevando-se, pois, a pena na proporção de um terço, resulta ela em sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, mais setecentos e setenta e sete dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Por força do montante da pena e da reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o acusado Lucas Roberto Falcão Timoteo como incurso nas penas do art. 33, caput, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, a cumprir sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar setecentos e setenta e sete dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

P.R.I.

Bauru, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA